

Existe-t-il un droit non contraignant?

Un constat

Existence de lois imparfaites

Existence de lois non normatives

Existence de la soft law / droit mou

Loi imparfaite

Loi dont la violation ne donne pas lieu à sanction

Loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Question des injures/diffamation à l'égard des Harkis

Art.5. Sont interdites

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

Mais pas de sanction jusqu'à l'adoption d'une autre loi en 2012

Constitution de 1958

Art. 13

- Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
- Quid si pas signature ?
 - Cas lors de la cohabitation F. Mitterrand/J. Chirac
 - Pas de sanction

Loi non normative

Loi qui ne comporte pas de prescription

Vague déclaration

Vague objectif

Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école adoptée 2005

- Art. 7: « L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.

Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents

Conseil Constitutionnel censure : dispositions manifestement dépourvues de toute portée normative (2005)

Loi mémorielle

Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides (adoptée le 23 janvier 2012)

Conseil constitutionnel **Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012**

« qu'une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi »,

Le droit mou / la soft law

Un élément très perturbateur

Salué par les uns

Critiqué par les autres

« droit à l'état gazeux » (Conseil d'Etat)

En développement croissant

(renvoi infra)

b- Les théories explicatives

Comment expliquer l'existence du Droit ?

Comment expliquer cette règle coercitive ?

Deux grands courants

Doctrines du droit naturel

Doctrines positivistes

Doctrines du droit naturel

Grotius, Puffendorf

Très liée à philosophie des Lumières

Conception du droit: finalité = idéal de justice, très proche du devoir moral

Droit naturel: ensemble de principes immuables et universels qui s'imposent à l'homme. L'homme les découvre grâce à la raison

DDHC « l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits »,

doctrines positivistes

Le droit résulte de la réalité positive: celle qui existe

Mais qu'est-ce que la réalité positive?

Elle peut-être

- sociale, sociologique: positivisme sociologique dérivé de la science, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie... (A. Comte)
- juridique :
 - la réalité sociale est celle exprimée par la norme : positivisme normativiste - Hans Kelsen
 - la réalité sociale est celle de la volonté: positivisme volontariste

2- LES BRANCHES DU DROIT

Pluralité de summa divisio des branches du droit

Droit public/droit privé

Droit interne/droit international

Droit international/droit européen

Et elles peuvent se combiner

Droit international public/droit international privé

Droit public/Droit privé

Droit public

Droit qui vise à organiser l'Etat et les collectivités publiques et à régir leurs rapports avec les particuliers

Droit privé

Droit qui vise à régir les rapports entre les particuliers

En entrant dans le détail: identification des subdivisions

Droit public

Droit constitutionnel

Droit administratif

Droit des finances publiques

Droit international public

Droit constitutionnel

Règles relatives à l'Etat et au pouvoir politique – droit de l'autorité publique (Georges Vedel)

Qu'est-ce qu'un Etat?

La Palestine est-elle un Etat

Le Sahara occidental est-il un Etat

Quelles règles s'appliquent à l'Etat ?

Quelles sont les formes de l'Etat ?

Quels sont les attributs de l'Etat et de ses démembrements?

Quels sont les pouvoirs de l'Etat?

Droit ancien et en évolution

Schématiquement : 3 grandes composantes

- Les institutions politiques
- Le système normatif
- Le droit substantiel : approche née à partir de l'étude de la jurisprudence du conseil constitutionnel & qui traite des droits fondamentaux et des libertés

Droit administratif

Ensemble de règles qui s'appliquent à l'administration publique à ses organes, aux actes qu'ils adoptent et aux relations entre ces organes de l'administration entre eux et entre eux et les personnes.

- Organisation administrative de l'Etat: différence Etat, régions, départements
- Les moyens d'action : le service public, la police, le contrat, la fonction publique
- Les biens : droit du domaine public
- La responsabilité administrative

Finances publiques

Ensemble des règles relatives aux recettes et aux dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la protection sociale et des organismes publics.

Droit international public

Droit international public: Ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États, entre les États et les organismes internationaux ainsi qu'entre les organismes internationaux eux-mêmes.»

- Qu'est-ce qu'un Etat ?
- Qu'est-ce qu'une organisation internationale ?
- Qu'est-ce qu'un traité international

Droit européen

Droit du Conseil de l'Europe

- Droits de l'homme
- Démocratie
- État de droit

- **Droit de l'Union européenne**

- Elaboration d'un marché intérieur, d'un espace de liberté, de sécurité et de justice
- Des politiques variées

Droit privé

- Droit civil
- Droit commercial
- Droit du travail
- Procédure civile
- Droit de la famille.....

Le droit civil

C'est le droit commun



Droit commun?

Définition: règles applicables à une situation si aucune autre branche spécifique du droit n'est pertinente dans cette affaire

Que couvre-t-il

- état des personnes (nom, domicile...)
- la famille (filiation, successions) et le statut matrimonial (mariage, divorce)
- le droit des obligations (contrat, dettes, créances...)

Le droit commercial

Droit issu du droit civil

Autonomisation / droit civil car adaptation aux besoins particuliers du commerce et des commerçants

Par exemple importance aujourd'hui du secret des affaires

- Règles sur les sociétés, le fonds de commerce
- Règles sur les actes de commerce (art. L. 110-1 code de commerce: achat de bien pour la revente , entreprise de location de meubles lettre de change, cautionnement
- Règles du contrat de transports

Droit du travail – Droit social

Droit du travail : ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre employeurs privés et salariés, à l'occasion du travail

- Relations individuelles de travail (contrat de travail)
- Relations collectives (grève, négociation et conventions collectives, institutions représentatives du personnel)

Droit social : ajout des règles relatives à la protection sociale; règles visant à garantir les travailleurs contre divers risques sociaux

- Conditions de travail : hygiène et sécurité; accident du travail
- Chômage
- Maladie

La summa divisio droit privé / droit public n'est pas si simple

Il existe des droits hybrides

Impossible de les rattacher totalement soit au droit privé soit au droit public

Droit pénal

Volet droit public: punir les infractions

Infraction? Trouble à l'ordre social, à l'intérêt général

Mais: volet droit privé: les infractions sont aussi au détriment des personnes privées

Vol: trouble à l'ordre social et à la personne victime de vol

Droit Fiscal

Ensemble des règles régissant les impôts

Mixte?

Fonction des impôts: alimenter le budget de l'Etat

Le budget de l'Etat sert aux dépenses de l'Etat

santé, éducation, justice, culture etc....

En lien avec les missions d'intérêt général de l'Etat

Les impôts sont fixés par l'Etat et perçus sur les personnes physiques ou morales : relations Etat/particuliers

Volet droit public

Mais : en lien avec droit des sociétés; droit immobilier, droit de la famille

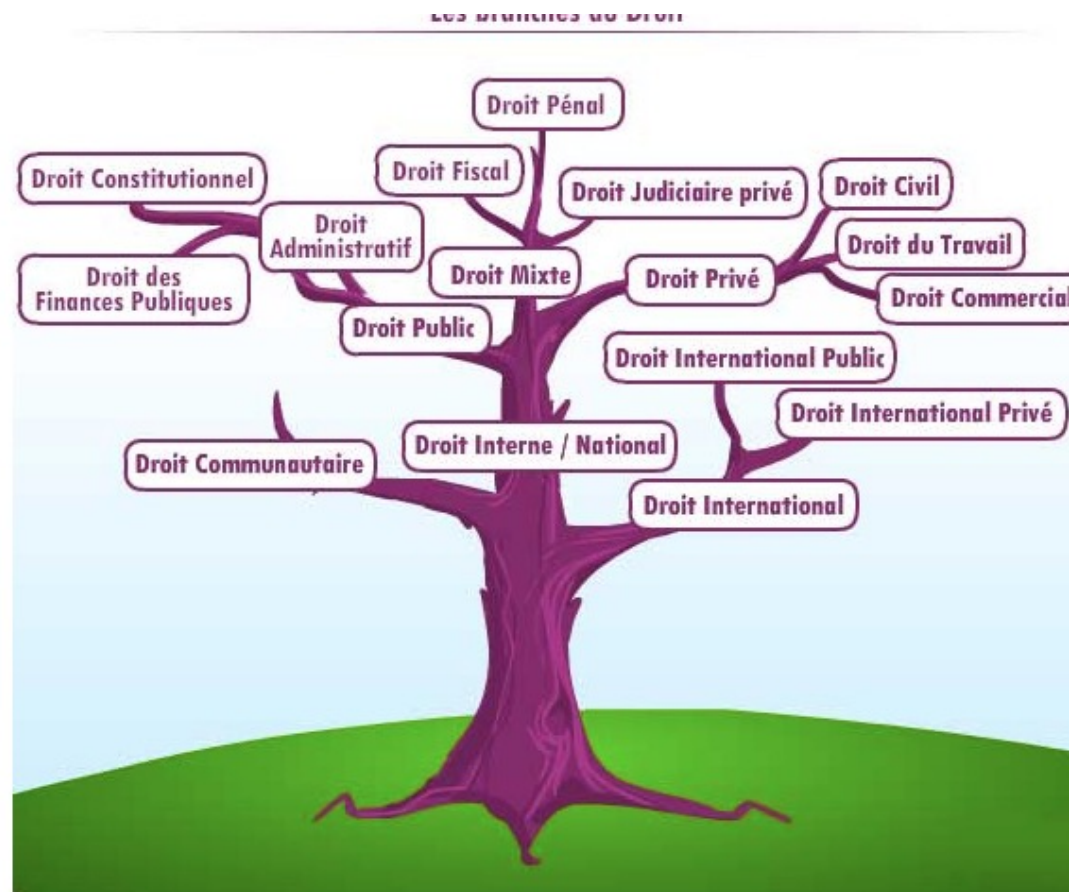
Volet droit privé

Droit judiciaire privé

Volet droit public: on parle de justice

Justice = service public

Mais litiges de droit privé



Source: Introduction au droit, E. Cadou, UNJF

Autonomie de certaines branches du droit

Droit fiscal

En droit pénal: interdiction du racolage (jusqu'en 2016)

Mais imposition des revenus du racolage

La summa divisio droit public/droit privé n'est pas si simple (suite)

Car mouvement de constitutionnalisation du droit

Constitutionnalisation du droit

Mouvement lié au rôle croissant du Conseil Constitutionnel

Cons. Const. 16 juillet 1971 (n° 71-44 DC)

Décision relative à la liberté d'association

Création du bloc de constitutionnalité

Bloc de constitutionnalité

Ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle qui s'impose aux pouvoirs législatif, exécutifs, aux autorités administratives, aux autorités juridictionnelles et aux particuliers

Normes de référence utilisées par le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité de la loi

Au-delà du texte Constitution de 1958

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789
- Préambule de la constitution de 1946
- Charte de l'environnement de 2004
- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Textes qui consacrent des droits et libertés fondamentales

Garantis par le Conseil Constitutionnel

Acquièrent valeur constitutionnelle

- Liberté d'association
 - Régie par loi 1901
 - Association : accord de droit privé
 - Constitutionnalisée par CC. Déc 1971
- Droit d'accès à internet
 - Contrat entre fournisseur d'accès et utilisateur : droit privé
 - Loi Hadopi : commission de protection des droits peut suspendre l'accès à internet
 - Déc. n° 2009-580 DC, 10 juin 2009: confier ce pouvoir à commission de protection des droits pose problème
 - Ce n'est pas une juridiction
 - Suspension = limitation droit accès à internet

- Vie privée
 - Code civil art. 9
 - Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité

- Liberté du commerce et de l'industrie
 - « Décret d'Allarde » Loi 2 et 17 mars 1791 & loi « Le Chapelier »
 - DC n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 – loi sur les nationalisations
- Sauvegarde de la dignité de la personne humaine
 - Lois relatives au respect du corps humain et au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, 29 juillet 1994: possibilité de détruire des embryons surnuméraires (embryons congelés et non utilisés à l'expiration d'un délai de 5 ans)
 - Question du corps humain: code civil art. 16 & suiv (issues de la loi 1994)
 - DC 94-343/344, 27 juillet 1994 : sauvegarde dignité personne humaine doit être respectée (est respectée) par le législateur

- Non rétroactivité de la loi
 - Rétroactivité de la loi pénale plus douce
 - Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981
 - Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
- Présomption d'innocence

Cons. const., 2 févr. 1995, déc. n° 95-360.

Résultats

Fondements constitutionnels du droit privé

Constitutionnalisation du droit privé, pénal, commercial etc....

Le droit est divisé en branches
Ces branches ne sont pas isolées les unes des autres

Reste à ordonner tout cela

Le droit forme un système juridique

3- Le système juridique

Système juridique

Ensemble de règles considérées sous le rapport de ce qui en fait la cohérence, celle-ci pouvant tenir, s'il s'agit du droit d'un pays, aux caractéristiques nationales de ce dernier (ex. système juridique français), ou, s'il s'agit au sein d'un ordre juridique, d'un faisceau de règles, au parti législatif qui l'inspire (ex. système légal des preuves de la filiation) (Cornu)

Système juridique fermé

Postulat: complétude de la loi.

Le législateur a tout prévu explicitement ou au minimum implicitement.

Pas de lacune du droit

Système juridique complet

Conséquences

Loi = source principale du droit

L'interprète ne crée pas de droit

Système juridique ouvert

Postulat : indétermination du droit

Règle de droit comporte des zones d'ombre, de doute.

En d'autres termes, la réalité de la vie – c'est pour cela que l'on appelle cette école l'école réaliste – démontre l'existence de cas ne rentrant pas dans les prévisions de la loi.

Conséquences

Loi : elle peut-être lacunaire. Et cela n'est pas un drame.

L'interprète : source de droit

Typologie des systèmes juridiques

système romano germanique

common law

Système de droit divin

systeme romano germanique

- Droit écrit
- Prévalence de la loi
- Compilé dans des codes
- Très lié à école du droit naturel
- Rôle du juge interprète: limité en principe

Common law

- Prévalence du droit non-écrit
- Construit progressivement au gré des précédents
- Prévalence du juge

Système de droit divin

Droit musulman

Droit indien (droit divin secondaire)

Existence de règles qui ordonnent la diversité

Objet du cours

Conception du cours

Raisonner

Raisonnement juridique

=

Raisonnement syllogistique (Syllogisme)

Majeure: Règle de droit

Mineure : Faits

Conclusion : Résultat de la confrontation majeure et mineure